

사이버 명예훼손에 대한 형벌권 행사와 표현의 자유의 형사법적 한계*

황정훈** · 송현정***

국 | 문 | 요 | 약

디지털 환경에서 표현의 자유와 명예 보호의 관계는 전통적인 사후적 형사책임 구조만으로는 설명되기 어렵다. 고전적 형법은 위법한 표현 이후 행위자에 대한 사후적 처벌을 통해 법질서를 회복하는 구조를 전제로 하나, 온라인 플랫폼을 통한 정보의 즉각적·대규모 확산은 명예훼손, 혐오표현, 허위정보로 인한 인격권 침해를 단기간에 광범위하고 회복 곤란한 수준으로 심화시키고 있다. 이에 따라 국가는 단순한 사후적 형벌권 행사에 머무르지 않고, 기본권의 객관적 가치질서에 근거한 보호 의무를 적극적으로 이행할 필요가 있다. 이러한 맥락에서 최근의 플랫폼 규제는 국가가 직접 표현을 통제하기보다, 플랫폼 사업자에게 신고·삭제 절차, 사유 고지, 내부 불복절차, 투명성 보고 등의 의무를 부과하는 협력적 집행 모델을 채택하고 있다. 이는 플랫폼을 공론장의 준규제적 행위자로 전제하고, 불법 표현 대응에 공적 책임을 제도화하려는 시도라는 점에서 의의를 가진다. 디지털 환경에서 구조적으로 취약한 지위에 놓인 소수자 및 사회적 약자는 혐오표현과 사이버 명예훼손의 주요 피해자가 되는 경향이 있으므로, 이들에 대한 실효적 보호는 표현의 자유 보장 체계 내에서 중요한 고려 요소로 기능한다.

그러나 이러한 간접 규율 방식은 플랫폼의 선제적 삭제 권한을 확대시켜 과잉 삭제 및 사적 검열의 위험을 초래할 수 있으며, 국가권력의 외주화라는 헌법적 문제를 야기할 가능성도 내포한다. 사이버 명예훼손에 대한 형벌권 행사는 단순한 사후 처벌의 문제가 아니라, 표현의 자유와 명예권이라는 기본권 충돌을 어떻게 제도적으로 조정할 것인가의 문제로 이해되어야 한다. 플랫폼에 대한 의무 부과는 원칙적으로 정당화될 수 있으나, 그 정당성은 절차적 공정성, 투명성, 다층적 감독 및 실효적 불복절차를 통해 지속적으로 검증되어야 한다. 이는 형사법적 사후책임 구조를 보완하는 새로운 규범적 거버넌스 모델로 평가될 수 있으며, 동시에 표현의 자유의 형사법적 한계를 재정립하는 지속적인 헌법적 통제를 요구하는 영역이라 할 수 있다.

DOI : <https://doi.org/10.36889/KCR.2026.3.31.1.31>.

❖ 주제어 : 표현의 자유, 사이버 명예훼손, 플랫폼 거버넌스, 디지털 서비스법, 비례원칙

* 이 논문은 2021년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임
(NRF-2021S1A5B5A16077340)

** 호서대학교 법학연구소 연구원, 법학박사(Ph.D).

*** 한국외국어대학교 대학원 법학과, 통번역학석사

I. 서론

오늘날 소셜 네트워크는 정보의 생산과 유통, 사회적 의사소통의 핵심 기반으로 자리 잡으며, 개인과 사회 전체의 공론 형성에 중대한 영향을 미치는 공간으로 기능하고 있다. 그러나 이러한 확장성과 파급력만큼 허위 정보, 혐오 표현, 명예훼손 등 다양한 형태의 유해·불법 정보가 온라인상에서 빠르게 확산되는 문제도 심화되고 있다. 이에 따라 표현의 자유라는 기본권을 보호하면서도, 공익을 저해하는 불법 정보의 확산을 효과적으로 규율할 법적·제도적 장치를 마련하는 것은 현대 국가의 공통된 과제가 되고 있다.¹⁾

유럽연합 디지털 서비스법(Digital Services Act, DSA)은 국가가 직접 표현을 제한하기보다는, 플랫폼 사업자에게 신고·심사, 삭제 사유 고지, 내부 불복절차, 투명성 보고, 감독 협력 의무 등을 부과하는 절차적·조직적 집행 구조를 도입함으로써, 플랫폼을 단순한 중개자가 아닌 공론장 형성에 실질적 영향을 미치는 준규제기관적 행위자로 전제하고 있다. 특히 DSA 제16조 「통지 및 조치 메커니즘」, 제17조 「결정 이유의 고지」, 제20조 「내부 불복처리 시스템」, 제21조 「법원 외 분쟁해결」은 삭제·제한 과정에서 이용자의 권리를 보호하는 절차적 장치를 마련하며, 제15조·제24조 「투명성 보고 의무」와 제51조 이하 「감독 및 집행」 규정은 외부 통제를 강화한다. 나아가 제34조 「위험 평가」, 제35조 「위험 완화 조치」, 제27조 「추천 시스템의 투명성」은 알고리즘과 운영구조 전반을 기본권 관점에서 관리하도록 규정함으로써, 표현의 자유와 인격권 간 충돌을 제도적으로 조정하는 다층적 거버넌스 모델로의 전환을 의미한다.²⁾

이에 본 논문은 디지털 서비스법을 중심으로 플랫폼 규제의 헌법적 정당성과 구조적 특징을 분석하고, 표현의 자유 보장과 불법 정보 규제 간의 균형을 설정하기 위한 적절한 절차, 플랫폼 책임 범위, 이용자 권리 보장 방안을 검토하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 디지털 환경에서 기본권 충돌 문제를 해결하기 위한 개선 방향을 모색하고자 한다.³⁾

1) 이권일, “독일에서의 규제 논의의 현황과 과제: 독일 네트워크법(NetzDG)과 유럽연합의 디지털 서비스법(DSA)을 중심으로”, 공법학연구 제25권 제2호(2024), 3-30면.

2) 정상민, “소비자 분쟁과 온라인 분쟁해결(ODR): 독일에서의 비판적 논의와 그 시사점을 중심으로”, 고려법학 제115호(2024), 141-144면.

II. 사이버 명예훼손과 표현의 자유의 형사법적 구조

1. 온라인 명예훼손과 형사법적 기본권 충돌

가. 디지털 환경에서 명예훼손의 특수성 및 위험 확대

독일에서 표현의 자유는 기본법 제5조에 의해 헌법적으로 보장되는 핵심 권리로서, 개인의 의견 표명뿐 아니라 정보의 수집·전달 및 언론의 자유까지 포괄하는 민주적 공론장의 기초를 형성한다. 그러나 디지털 환경과 소셜 네트워크의 급속한 확산은 이러한 표현의 자유를 둘러싼 형사법적 충돌 구조를 질적으로 변화시키고 있다. 온라인 공간에서는 허위 정보, 명예훼손, 혐오표현이 시간적·공간적 제약 없이 급속히 확산되며, 그로 인한 인권권 침해는 광범위하고 회복이 곤란한 특성을 가진다. 전통적 형사법은 명예훼손과 같은 위법 행위에 대해 사후적으로 형벌을 부과함으로써 법질서를 회복하는 구조를 취해 왔다. 그러나 디지털 환경에서의 피해 확산 속도와 규모는 이러한 사후적 책임 구조만으로는 피해의 실효적 구제 및 예방이라는 형사법의 보호기능을 충분히 달성하기 어렵다는 한계를 드러낸다. 이에 따라 형사법은 단순한 사후 제재 수단을 넘어, 기본권 간 충돌을 조정하는 규범적 기능을 보다 적극적으로 수행할 필요가 있다는 논의가 형사법 학계에서도 지속적으로 제기되어 왔다. 구체적으로, 형사법 이론에서는 명예훼손죄의 구성요건과 위법성 판단에 있어 진실성, 공익성, 상당성 등의 판단 기준을 통해 표현의 자유를 최대한 보장하려는 해석론이 발전해 왔으며, 동시에 과잉 형벌화의 위험을 방지하기 위한 비범죄화 또는 형벌권의 보충성 원칙에 대한 논의도 병행되어 왔다. 또한 온라인 환경에서는 정보통신망을 이용한 명예훼손의 가중처벌 문제, 플랫폼을 통한 2차·3차 확산에 대한 책임 귀속 문제, 그리고 삭제·차단 등 비형벌적 수단과 형사제재의 관계 설정 등이 중요한 쟁점으로 다루어지고 있다. 이러한 논의는 형사법이 단순한 사후적 응보 체계를 넘어 예방적·조정적 기능을 어떻게 수용할 것인지에 대한 구체적 방향을 제시한다. 특히 디지털 환경에서는 구조적으로 취약한 지위에 놓인 소수자 및 사회적 약자가 혐오표현과 사이버 명예훼손의 주요 피해자가 되

3) 신상현, “위법한 명예훼손 게시물의 삭제 및 차단의무에 관한 소셜네트워크 운영자의 형법적 책임 : NetzDG에 대한 비판적 검토”, 법학연구 제20집 제3호(2017), 61-92면.

는 경향이 있으며, 이로 인한 인격권 침해는 개인의 사회적 존재 기반 자체를 위협할 수 있다. 따라서 이들에 대한 실효적 보호는 단순한 정책적 고려를 넘어, 표현의 자유 보장 체계 내에서 형사법적 한계를 설정함에 있어 중요한 규범적 요소로 기능한다. 이는 형벌권 행사의 정당성과 한계를 논증하는 과정에서, 보호법익의 중요성과 피해의 구조적 불균형을 함께 고려해야 함을 의미한다. 결국 디지털 환경에서의 명예훼손 문제는 표현의 자유와 인격권이라는 기본권 충돌을 전제로 하되, 이를 해결하기 위한 형사법적 대응 역시 보다 정교하게 구조화될 필요가 있다. 즉, 형벌권은 최후수단성 원칙에 따라 제한적으로 행사되어야 하지만, 동시에 온라인 공간에서의 급속한 피해 확산을 고려할 때 일정한 예방적 기능과 결합된 방식으로 재구성될 필요가 있다. 이러한 관점은 독일의 온라인 규율 체계 및 관련 입법 논의와도 연결되며, 사후적 형사책임과 예방적 규제 수단 간의 역할 분담을 형사법적 관점에서 구체화하는 작업으로 이어진다.⁴⁾

나. 국가의 형사법적 보호의무에 따른 표현의 자유의 규범적 한계

디지털 환경에서 표현의 자유와 명예 보호 사이의 긴장은 플랫폼의 영향력 확대와 정보 확산 속도의 비약적 증가로 인해 한층 복잡한 양상을 띤다. 특히 온라인 공간에서의 명예훼손, 허위정보, 혐오표현은 단기간 내 광범위하게 확산되며, 전통적인 사후적 형사책임 중심의 대응만으로는 피해 회복과 기본권 보호의 실효성을 확보하기 어렵다는 한계를 드러낸다. 독일 형법을 비롯한 기존 형사법 체계는 게시물·댓글·멀티미디어 콘텐츠가 실시간으로 재생산·유통되는 디지털 환경의 특수성을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 이에 따라 규범적 대응의 공백이 발생하고 있다.

이러한 한계를 보완하기 위해 유럽연합의 디지털 서비스법(DSA)은 플랫폼 사업자에게 신고 및 심사 절차, 삭제 사유의 고지, 내부 불복절차, 법원 외 분쟁 해결, 투명성 보고, 외부 감사 및 감독 협력 등 다층적인 절차적·조직적 의무를 부과하고 있다. 이를 통해 플랫폼은 단순한 중개자를 넘어 공론장 형성에 실질적 영향을 미치는 준규제적 행위자로 자리매김하며, 불법 콘텐츠에 대한 대응 과정에서 공적 책임을 제도적으로 분담하게 된다.

4) 권형돈, “인터넷에서 표현의 자유와 그 규제법리: 혐오표현·거짓정보에 대한 독일의 대응을 중심으로”, 사법발전재단 통권 제51호(2020), 3-34면.

다만, 이러한 논의에도 불구하고 사이버 명예훼손죄와 표현의 자유의 관계를 형사법적 관점에서 구체적으로 정교화하려는 기존 형사법 학계의 축적된 논의가 충분히 반영되지 않는다면, 결론은 형벌권의 한계나 형법적 보호기능의 보완, 형사법적·헌법적 질서의 재구성과 같은 추상적 수준에 머무를 위험이 있다. 이미 형사법 학계에서는 위법성 조각사유의 확장, 구성요건의 명확화, 피해자 보호 중심의 절차 개선, 형벌과 비형벌적 수단 간의 기능적 분담 등 다양한 구체적 방안이 논의되어 온 만큼, 이에 대한 체계적 검토가 병행될 필요가 있다. 이를 토대로 비로소 형벌권 행사와 표현의 자유 보장 사이의 긴장을 완화할 수 있는 보다 실질적이고 정책적인 대안이 도출될 수 있을 것이다.

한편, 디지털 환경에서 구조적으로 취약한 지위에 놓인 소수자와 사회적 약자는 혐오표현과 사이버 명예훼손의 주요 피해자가 되는 경향이 있다. 따라서 이들에 대한 실효적 보호는 단순한 형사정책적 고려를 넘어 표현의 자유 보장 체계 내부에서 중요한 규범적 요소로 작용해야 하며, 형사법적 개입의 범위와 방식 역시 이러한 보호 필요성과의 조화를 전제로 재구성될 필요가 있다.⁵⁾

형사법적 관점에서 이러한 구조는 다음과 같은 의미를 가진다. 첫째, 기존 독일 형법 제185조 내지 제187조에 따른 사후적 처벌만으로 온라인 명예훼손 피해 확산과 회복 곤란성을 해결할 수 없으므로, 플랫폼 규제를 통한 예방적·구조적 통제가 형사법적 보완 장치로 기능한다. 둘째, 플랫폼 규제는 자율적 판단과 삭제 권한을 확대함으로써 과잉 삭제(overblocking)와 사적 검열 가능성을 내포하며, 이는 표현의 자유 제한으로 작용할 수 있다. 따라서 규제 정당성은 국가의 보호의무 이행이라는 공익적 목적과 비례성 원칙, 과잉금지 원칙, 절차적 공정성 준수 여부에 따라 평가되어야 한다.⁶⁾

결과적으로, 디지털 환경에서 형사법적 관점의 표현의 자유 규범적 한계는 단순히 불법 콘텐츠 제거 의무에 국한되지 않고, 플랫폼에 대한 절차적·조직적 책임 부여, 이용자 권리 보호, 위험 관리, 외부 감독 체계 등 다층적 통제 장치를 통해 지속적으로 검증되고 조정되어야 한다. 이는 자유와 통제를 단순 대립으로 보는 시각을 넘어, 형사법

5) Jarass Hans D., Kment Martin., Pieroth Bodo., Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Kommentar, München, C.H. Beck, 2020, pp. 34-56.

6) Heldt Amélie Pia., Reading between the lines and the numbers: an analysis of the first NetzDG reports, Internet Policy Review: Journal on Internet Regulation, 8(2), 2019, pp. 1-18.

과 플랫폼 규제를 연계하여 표현의 자유와 명예권 간 충돌을 구조적으로 조정하고 제도화하는 방향으로 나아가야 함을 시사한다.⁷⁾

2. 디지털 환경에서 형사법적 관점의 플랫폼 규제

가. 디지털 플랫폼 규제의 형사법적 책임과 표현의 자유 제한

디지털 환경에서 명예훼손 및 불법 표현 규제는 전통적 사후적 형사 책임 구조만으로는 실효성을 확보하기 어렵다. 독일 형법은 온라인 게시물이나 댓글에 대해서도 적용 가능하지만, 정보가 플랫폼을 통해 즉시·대규모로 확산되는 현실에서는 피해 회복과 기본권 보호가 지연되거나 불가능할 수 있다. 이에 따라 국가의 보호의무(Schutzpflicht)는 단순한 사후적 형벌 집행을 넘어, 구조적·예방적 규율을 요구한다. 디지털 서비스법(DSA) 및 독일의 대형 소셜 네트워크 규제 모델은 이러한 요구에 대응하여, 플랫폼 사업자에게 불법 콘텐츠 신고·심사 절차를 법적 의무로 부과하고, 삭제·차단 조치 시 사유 고지 및 내부 불복절차, 투명성 보고, 감독기관과 협력 의무를 규정한다(DSA 제16~21조, 제15·24·51조). 형사법적 관점에서 이러한 구조는 다음과 같은 의미를 가진다. 첫째, 독일 형법 제185조 내지 제187조에 따른 사후적 형사책임만으로는 온라인 명예훼손 피해를 신속하게 대응할 수 없으므로, 플랫폼 규제를 통한 예방적·구조적 통제가 형사법적 보완 장치로 기능한다. 둘째, 플랫폼 규제는 사업자가 불법성 판단과 삭제 여부를 선제적으로 결정하도록 하여, 과잉 삭제(overblocking)와 사적 검열 위험을 내포한다. 따라서 규제의 헌법적·형사법적 정당성은 국가의 보호의무 이행이라는 공익 목적과 표현의 자유 제한의 비례성·과잉금지 준수 여부를 기준으로 평가되어야 한다. 결과적으로, 디지털 플랫폼 규제에서 사업자 의무의 형사법적 규범구조는 기본권 충돌 상황에서 국가의 보호의무와 표현의 자유 간 긴장을 조정하는 기능을 수행한다. 이는 플랫폼을 협력적 집행 구조(cooperative enforcement structure)로 전환하여, 형사법적 사후 책임과 예방적·구조적 규율을 연계하는 새로운 규율 모델로 이해할 수 있다⁸⁾

7) 박신욱, “온라인서비스제공자의 책임 및 그 확장에 관한 NetzDG 연구”, 법학연구 21(2) (2018), 269-304면.

8) 박희영, “독일의 가짜 뉴스(Fake News)에 대처하기 위한 ‘소셜 네트워크 법집행법’(NetzDG)”, 외

나. 형사법적 관점에서 본 디지털 플랫폼 규제의 정당화 구조

독일 기본법 제5조 제1항은 표현의 자유를 민주적 질서의 핵심적 기본권으로 보장한다. 그러나 제2항은 일반 법률, 청소년 보호 규정, 개인의 명예권에 의한 제한을 명시하여 표현의 자유가 절대적 권리가 아님을 전제한다. 이는 표현의 자유가 타인의 인격권 및 공동체적 법익과 조화되어야 함을 의미한다. 독일 형법 제185조 내지 제187조는 모욕, 명예훼손, 허위사실 적시를 처벌함으로써 이러한 제한을 구체화한다. 국가는 기본권의 객관적 가치질서로부터 도출되는 보호의무에 근거하여, 플랫폼 사업자에게 신고·삭제·절차 보장 등의 조직적 의무를 부과하는 구조를 형성한다. 이러한 플랫폼 규제는 형사법적 보호법익을 실효적으로 보장하기 위한 보완적 장치로 이해된다. 다만 사업자가 불법성 여부를 선제적으로 판단하는 구조는 과잉 삭제와 사적 검열의 위험을 내포하므로, 그 정당성은 비례성 원칙에 따라 엄격히 심사되어야 한다. 디지털 플랫폼 규제는 독일 기본법 제5조의 제한 구조와 독일 형법의 보호법익 체계를 연결하여, 사후적 형사책임과 예방적 구조 통제를 결합하는 형사법적 규율 모델로 평가할 수 있다.⁹⁾

다. 형사법적 관점에서 본 절차적 통제와 투명성에 의한 과잉규제 방지

독일 기본법 제5조는 표현의 자유를 보장하면서도 일반 법률과 명예 보호에 의한 제한을 허용한다. 동시에 제19조 제4항은 공권력 행사에 대한 권리구제 가능성을 보장한다. 디지털 환경에서 플랫폼 사업자가 삭제·차단 결정을 수행하는 경우, 이는 형식상 사적 행위이지만 실질적으로는 표현의 자유에 중대한 영향을 미친다. 따라서 그 판단 과정은 법적 근거, 이유 제시, 당사자 통지, 이의제기 절차 등 절차적 합리성을 갖추어야 하며, 그렇지 않을 경우 과잉 삭제나 사실상의 사적 검열로 전환될 위험이 있다. 불명확한 기준에 따른 삭제는 표현의 자유에 대한 예측 불가능한 제한을 초래하며, 이는 형벌규범의 명확성 요구와 긴장관계에 놓인다. 따라서 플랫폼 규제는 그 판단 기준과 집행 과정이 외부적으로 검증 가능하도록 설계되어야 한다. 유럽연합 디지털 서비스

국법 제동향(2018), 61-65면.

9) Witt Hendrik., Schuh Mathias., Tatbestand, Zweck und Zweckentfremdung des Auskunftsrechts nach Art. 15 DSGVO, Computer und Recht, vol. 39, no. 4, 2023, p. 228.

법은 이러한 구조를 제도화하여, 삭제 사유의 통지, 내부 불복절차, 독립적 분쟁해결제
도, 정기적 투명성 보고 및 감독기관 협력 의무 등을 규정한다. 이는 실체적 금지의 확
대보다는 절차 중심의 거버넌스를 통해 규제의 작동 방식을 통제하려는 접근으로 평
가된다. 신고 건수, 삭제 비율, 처리 기준 등이 공개될 때에만 비례성 심사가 실질적으
로 가능하며, 과잉규제 여부 또한 객관적으로 점검될 수 있다. 절차적 통제와 투명성은
플랫폼 규제의 형사법적 정당성을 지탱하는 구조적 전제이다. 사후적 형사책임과 예
방적 플랫폼 통제가 결합되는 상황에서, 규제 권한의 행사 과정이 공개되고, 불복이 가
능하며, 감독이 다층적으로 이루어질 때에만 표현의 자유의 본질적 내용은 침해되지
않는다. 이러한 다층적 통제 구조 속에서 디지털 환경의 명예훼손 및 불법 표현 규제는
기본권 보호와 자유 보장을 조화시키는 형사법적 규율 모델로 기능할 수 있다.¹⁰⁾

3. 표현의 자유 제한에 대한 헌법적 통제의 형사법적 제도화

가. 형사법적 관점에서 절차적 정당성 원칙과 플랫폼 권한 행사의 한계

표현의 자유라는 기본권을 보장하면서도 공익을 저해하는 불법 정보의 확산을 효과
적으로 규율하기 위해서는, 국내 디지털 환경에서 나타나는 규제 현실과 그 한계를 우
선적으로 검토할 필요가 있다. 우리나라에서는 온라인상 명예훼손과 허위정보 유통,
혐오표현 문제가 지속적으로 사회적 갈등을 야기해 왔으며, 특히 포털, SNS, 커뮤니티
등 플랫폼을 통한 정보 확산 구조 속에서 피해의 범위와 속도가 급격히 확대되는 양상
을 보인다. 현행법은 형법상 명예훼손죄, 정보통신망법상 명예훼손 및 임시조치 제도
등을 통해 이러한 문제에 대응하고 있으나, 주로 사후적 형사처벌 또는 권리침해 주장
에 기초한 임시적 게시물 차단 방식에 의존하고 있다. 그러나 이러한 규제 방식은 사이
버 명예훼손 영역에서 몇 가지 구조적 한계를 드러낸다. 첫째, 형사처벌 중심의 대응은
이미 확산된 정보로 인한 피해를 충분히 회복하기 어렵고, 피해자 보호의 실효성이 제
한된다. 둘째, 임시조치 제도는 신속한 권리구제를 가능하게 한다는 장점에도 불구하
고, 불명확한 판단 기준과 플랫폼의 자의적 결정 가능성으로 인해 과잉 삭제 또는 표현

10) González Fuster Gloria., Cambridge Analytica: A turning point in data protection?, European Data Protection Law Review (EDPL), 4(2), 2018, pp. 178-180.

위축을 초래할 위험이 있다. 셋째, 혐오표현이나 반복적·집단적 명예훼손과 같이 구조적 피해를 야기하는 유형에 대해서는 현행 형사법 체계가 충분히 정교한 대응 기준을 제시하지 못하고 있다. 특히 디지털 환경에서 구조적으로 취약한 지위에 놓인 소수자와 사회적 약자가 주요 피해자가 된다는 점에서, 단순한 사후적 제재를 넘어서는 실효적 보호 장치가 요구된다. 이와 같은 국내 규제 현실을 전제로 볼 때, 디지털 환경에서는 국가가 직접 표현을 통제하기보다는 플랫폼 사업자에게 신고 접수, 심사, 삭제·차단 의무를 부과하는 구조가 점차 강화되고 있다. 이 경우 플랫폼은 사적 주체임에도 불구하고 사실상 준규제기관적 지위에서 타인의 표현물에 대한 판단을 수행하며, 기본권에 대한 간접적 제한 효과를 발생시킨다. 형사법적 관점에서 이는 책임주의와 명확성 원칙을 절차적 차원에서 구현해야 할 필요성을 강하게 제기한다. 불명확한 기준이나 자의적 판단에 따른 삭제는 표현 행위자의 예측 가능성을 침해하고, 결과적으로 표현의 자유에 대한 과도한 위축 효과를 초래할 수 있다. 따라서 불법성 판단 기준의 구체화, 명백한 위법성과 해석이 요구되는 사안의 구분, 합리적이고 단계적인 심사 절차의 설정은 필수적인 통제 장치가 된다. 나아가 삭제·차단 결정에 대한 이유 제시, 당사자 통지, 이의제기 절차, 기록 보존 의무 등은 표현 제한이 비가시적이고 일방적으로 이루어지는 것을 방지하는 핵심 요소이다. 이러한 절차적 정당성 원칙은 형벌권의 보충성 원칙과도 긴밀히 연결된다. 즉, 플랫폼의 조치가 사실상 제재적 기능을 수행하는 경우에도, 이는 형사처벌을 대체하거나 선행하는 규율로서 최소한 형사법에 준하는 신중성과 통제 가능성을 갖추어야 한다. 동시에 혐오표현 및 사이버 명예훼손의 주요 피해자인 소수자와 사회적 약자에 대한 실효적 보호를 확보하기 위해서는, 단순히 삭제 여부를 판단하는 수준을 넘어 반복적·구조적 침해에 대한 대응 체계까지 고려되어야 한다. 플랫폼 규제에 대한 헌법적 통제는 권한 행사 과정의 예측 가능성과 절차적 통제 가능성을 확보하는 설계를 통해 구체화된다. 이는 사후적 형사책임과 예방적 플랫폼 규율이 결합된 현대적 규율 구조 속에서, 표현의 자유 제한을 정당화하기 위한 핵심적 제도 장치이며, 동시에 공익 보호와 기본권 보장 간의 긴장을 조정하는 형사법적·헌법적 접점으로 기능한다.¹¹⁾

11) 박신욱, 앞의 논문, 275-287면.

나. 형사법적 관점에서 본 내부 통제와 구조적 위험 관리

표현의 자유를 보장하면서도 불법 정보의 확산을 효과적으로 통제하기 위해서는, 개별 표현행위에 대한 사후적 책임 부과를 넘어 표현이 유통되는 구조 자체에 대한 규율 필요성이 제기된다. 우리나라의 경우에도 온라인 플랫폼을 중심으로 명예훼손, 허위정보, 혐오표현이 반복적·집단적으로 확산되는 문제가 지속되고 있으나, 현행 규제는 여전히 형법상 명예훼손죄나 정보통신망법상 게시물 삭제·임시조치 등 개별 행위 단위의 대응에 집중되어 있다. 이러한 방식은 피해 발생 이후의 사후적 대응에 머무르기 때문에, 동일·유사한 침해가 플랫폼 구조를 매개로 지속적으로 재생산되는 현실을 충분히 통제하지 못하는 한계를 가진다. 특히 현행 임시조치 제도는 권리침해 주장에 기반하여 게시물을 신속히 차단할 수 있도록 설계되어 있으나, 그 판단 기준과 운영 방식이 플랫폼 내부에 상당 부분 위임되어 있다는 점에서 자의적 결정이나 과잉 차단 가능성 등을 내포한다. 이는 표현의 자유를 위축시킬 위험이 있을 뿐만 아니라, 반복적·조직적 침해에 대한 구조적 대응에는 미치지 못하는 단편적 조치에 그칠 수 있다. 또한 혐오표현이나 집단적 명예훼손과 같이 사회적 약자를 주요 대상으로 하는 침해 유형은 개별 사건 단위의 처벌만으로는 충분한 예방 효과를 기대하기 어렵다는 점에서, 보다 체계적인 관리 접근이 요구된다. 이러한 맥락에서 형사법적 관점은 보호법의 침해가 구조적으로 반복되는 경우, 그 발생 원인으로서의 플랫폼 운영 구조 자체에 대한 통제를 요청한다. 대규모 플랫폼의 알고리즘 설계, 콘텐츠 추천 및 노출 방식, 신고 처리 인력과 기준의 설정은 특정 표현의 확산 가능성과 가시성을 결정하며, 이는 사실상 기본권 행사 조건을 형성하는 요소로 기능한다. 그럼에도 불구하고 현행법은 이러한 구조적 요소에 대한 명시적 규율을 충분히 마련하지 못하고 있어, 결과적으로 형사법적 보호의 공백이 발생할 수 있다. 따라서 플랫폼 내부에 신고·심사·이유 고지 체계를 명확히 구축하고 이를 일관되게 운영하도록 요구하는 것은, 사적 판단을 법적 기준에 종속시키는 중요한 수단이 된다. 특히 삭제·차단 조치에 대한 이유 제시와 기록 보존 의무는 외부적 검증 가능성을 확보함으로써, 플랫폼의 조치가 사실상의 제재 기능을 수행하더라도 책임주의와 명확성 원칙에 부합하도록 통제하는 역할을 한다. 나아가 이러한 내부 통제 장치는 단순한 개별 분쟁 해결을 넘어, 반복적 침해 유형을 식별하고 대응 기준을 축적하는 기능까지 수행할 수 있다. 최근 유럽연합의 규율은 이러한 내부

통제를 더욱 발전시켜, 플랫폼의 규모와 사회적 영향력에 따라 차등적 의무를 부과하고 위험 기반 관리 체계를 도입하고 있다. 특히 일정 규모 이상의 플랫폼에 대해 시스템적 위험 평가와 완화 조치를 요구하는 접근은, 개별 게시물 삭제라는 사후적 대응을 넘어 표현의 자유와 인격권 간 충돌이 반복적으로 발생하는 구조적 요인을 사전에 식별·관리하도록 하는 데 그 의의가 있다. 우리나라에서도 사이버 명예훼손과 혐오표현 문제에 효과적으로 대응하기 위해서는, 기존의 행위자 중심 형사책임 체계를 보완하여 플랫폼의 구조적 위험 관리 책임을 제도적으로 정립할 필요가 있다. 이는 표현의 자유를 과도하게 제한하지 않으면서도, 사회적 약자를 포함한 피해자 보호의 실효성을 제고하기 위한 필수적인 규범적 과제로 이해되어야 한다.¹²⁾

이와 같은 맥락에서 내부 통제와 구조적 위험 관리 의무는 플랫폼을 단순한 사적 서비스 제공자를 넘어, 형사법적 보호법의 체계와 실질적으로 연결된 책임 구조 안으로 편입시키는 핵심적 제도 장치로 이해될 수 있다. 이는 기존과 같이 개별 행위자에 대한 사후적 형사책임에만 의존하는 것이 아니라, 플랫폼 차원에서 반복적·구조적으로 발생하는 침해 위험을 사전에 관리하도록 함으로써 규율의 충위를 확장하는 접근이다. 개별 사건에 대한 형사책임과 조직 차원의 예방적 관리 의무를 유기적으로 결합하는 것은, 디지털 환경에서 심화되는 표현의 자유와 인격권 보호 간의 긴장을 사후 제재가 아닌 구조적 통제의 방식으로 조정하려는 형사법적 규율 모델로 평가할 수 있다. 이는 특히 사회적 약자와 소수자에 대한 반복적 침해를 완화하면서도, 과도한 형벌권 행사 없이 기본권 간 균형을 도모하려는 점에서 그 규범적 의의를 갖는다.¹³⁾

다. 투명성과 다층적 감독체계에 의한 권력 분산 및 외부 통제

디지털 환경에서 플랫폼은 불법 콘텐츠의 판단과 삭제·차단을 수행함으로써 사실상 공적 기능을 일부 대행하고 있으며, 이는 표현의 자유에 대한 실질적 제한 권한이 사적 주체에 의해 행사되는 구조를 형성한다. 우리나라에서도 방송통신심의위원회의 시정 요구, 플랫폼 사업자의 임시조치 및 자체 심사 기준 등이 결합된 형태로 콘텐츠 규제가

12) 김현수·전성호, “유럽연합 디지털서비스법안의 주요 내용 및 시사점”, 정보통신정책 연구원 (2020), 17-20면.

13) Hinrichs Lena., Die Regulierung von Online-Plattformen durch Digital Services Act und Digitale Dienste Gesetz, HRN, 2024, pp. 14-15.

이루어지고 있으나, 이러한 체계는 신속한 대응이라는 장점에도 불구하고 절차의 투명성과 판단 기준의 일관성 측면에서 한계를 노정하고 있다. 특히 시정요구 과정이나 플랫폼의 자율적 삭제 결정이 이용자에게 충분히 설명되지 않거나 외부적으로 검증되기 어려운 경우, 표현의 자유에 대한 위축 효과와 함께 사적 검열에 대한 우려가 제기될 수 있다. 이러한 국내 규제 구조는 유럽연합 디지털서비스법(DSA)이 지향하는 플랫폼 협력 모델과 대비될 때 그 한계가 보다 분명해진다. DSA는 플랫폼의 자율적 판단을 전제로 하되, 신고·심사·이유 고지·불복 절차를 제도화하고, 투명성 보고와 외부 감독을 결합함으로써 권한 행사의 전 과정을 공적 검증의 대상으로 편입시키고 있다. 반면 우리나라의 경우, 방송통신심의위원회를 중심으로 한 행정적 통제와 플랫폼의 자율적 조치가 병존하고 있음에도, 양자 간 역할 분담과 절차적 연계가 충분히 정교화되어 있지 않아 규제의 일관성과 책임 구조가 불명확한 측면이 있다. 형사법적 관점에서 이는 국가 형벌권의 통제를 받지 않는 사적 권력에 의해 표현이 실질적으로 제한되는 상황을 의미하며, 책임주의와 명확성 원칙이 우회될 가능성을 내포한다. 따라서 플랫폼의 권한 행사가 외부적으로 검증 가능하고, 공적 통제의 대상이 되는 다층적 구조를 구축하는 것이 필요하다. 구체적으로는 플랫폼의 삭제·차단 조치에 대한 이유 고지 및 기록 의무를 강화하고, 이를 바탕으로 독립적 감독기구나 사법적 심사를 통해 사후적으로 통제할 수 있는 체계를 마련해야 한다. 아울러 이러한 절차적·제도적 통제 모델은 국내 명예훼손 판례에서 발전되어 온 위법성 판단 기준 및 면책 법리와의 연계를 통해 그 실천적 함의를 구체화할 필요가 있다. 예컨대 공공의 이익에 관한 사항인지 여부, 사실 적시의 진실성·상당성, 표현 방식의 사회적 상당성 등은 이미 판례를 통해 축적된 판단 기준으로서, 플랫폼의 1차적 심사 기준으로 기능할 수 있다. 이를 제도적으로 반영할 경우, 단순한 자율적 판단이 아닌 법적 기준에 기초한 일관된 의사결정이 가능해지며, 과잉 삭제를 방지하면서도 명예훼손 피해에 대한 실효적 대응을 도모할 수 있다. 권력 분산과 다층적 감독체계는 플랫폼, 행정기관, 사법부 간의 기능적 분담과 상호 견제를 통해 구현되어야 한다. 이는 표현의 자유 제한 가능성이 존재하는 지점을 제도적으로 분절시키고, 각 단계마다 통제 장치를 작동시킴으로써 침해 위험을 최소화하는 방식이다. 나아가 투명성과 외부 통제를 강화하는 방향으로 국내 규제 체계를 재구성할 때, 공론장 규제의 신속성과 정당성을 동시에 확보할 수 있으며, 형사법적 보호법익과 표현의 자유 보장을 균형 있게 실현할 수 있을 것이다.¹⁴⁾

국내 규제 체계의 한계를 보완하기 위한 방향은 유럽연합 디지털서비스법(DSA)에서 보다 체계적으로 구현되고 있다. 동 규율은 단순히 플랫폼의 자율적 판단에 의존하는 것이 아니라, 투명성 보고 의무, 시스템적 위험 평가 및 완화 조치, 외부 감사, 감독 기관 간 협력 메커니즘 등을 결합하여 플랫폼 권한 행사를 다층적으로 통제하는 구조를 형성한다. 이는 개별 조치의 적법성뿐 아니라, 플랫폼 운영 전반에서 발생할 수 있는 구조적 위험을 지속적으로 점검·관리하도록 하는 점에서 특징적이다. 특히 사회적 영향력이 큰 초대형 플랫폼에 대해서는 일반적 의무를 넘어 강화된 책임을 부과하고, 중앙 차원의 감독 권한을 병행함으로써 영향력에 상응하는 규제 강도를 차등화하고 있다. 이러한 접근은 플랫폼의 자율성과 공적 책임을 결합하는 한편, 권한 집중으로 인한 표현의 자유 침해 가능성을 외부 통제를 통해 견제하려는 것이다. 이는 자율규제에 머무르던 기존 모델을 넘어, 플랫폼이 야기할 수 있는 구조적 위험을 공적 통제의 틀 안으로 편입시키려는 시도로 평가할 수 있으며, 우리나라에서도 방송통신심의위원회 중심의 사후적·개별적 규제 구조를 보완하기 위한 중요한 비교 기준을 제공한다.¹⁵⁾

다층적 감독과 외부 통제의 강화는 형사법적으로 형벌의 보충성 원칙과 긴밀히 연결된다. 즉, 디지털 환경에서 발생하는 모든 기본권 침해를 사후적 형사처벌에 의존하기보다는, 플랫폼 권한 행사의 과정 자체를 투명성과 외부 감독을 통해 통제함으로써 자의적 판단과 권한 남용을 예방적으로 억제하고, 형벌권은 최후수단으로 기능하도록 재정립하는 것이다. 이는 특히 우리나라와 같이 사후 처벌과 임시조치에 규제가 집중된 구조에서, 형벌권의 과잉 의존을 완화하고 규율 방식의 균형을 회복하는 데 중요한 의미를 가진다. 투명성 확보는 단순한 정보 공개를 넘어, 플랫폼의 삭제·차단 조치의 비례성과 최소침해 원칙에 부합하는지 판단할 수 있는 객관적 자료를 제공한다는 점에서 핵심적 기능을 수행한다. 나아가 다층적 감독체계는 특정 표현이나 집단에 대한 과잉 삭제 또는 차별적 집행이 이루어지는지를 구조적으로 점검할 수 있게 하여, 국내에서 문제되어 온 불투명한 심의 및 자율규제의 한계를 보완하는 역할을 한다. 투명성과 권력 분산 구조는 앞서 살펴본 내부 절차의 정교화 및 구조적 위험 관리 의무와 결

14) 小泉雄介., EUデータ保護規則案の動向と個人データ越境移転, ITUジャーナル, vol. 45, no. 11, 2015, 22頁.

15) Carmi E.-K., Comandé G., The Digital Services Act: A New Paradigm for Platform Accountability, Common Market Law Review, vol. 60, 2023, pp. 1-38.

합될 때, 플랫폼 규제를 헌법 질서와 형사법 원리에 정합적으로 편입시키는 완결적 장치로 기능한다. 이는 표현의 자유 보호와 불법 콘텐츠 대응이라는 상충하는 목표를 사후 처벌과 사전적 통제의 균형 속에서 조정하는 것으로, 디지털 환경에 부합하는 형사법적·헌법적 규율 모델의 지향점이라 평가할 수 있다.¹⁶⁾

Ⅲ. 디지털 서비스법과 온라인 플랫폼에서 표현의 자유

1. 디지털 서비스법의 제정 배경과 표현의 자유 관련 규범

가. 형사법적 관점에서 본 온라인 플랫폼 규제 필요성과 공익적 목표

대규모 플랫폼은 정보 유통의 관문으로 기능하며, 명예훼손·혐오표현·불법 정보의 확산이 단기간 내 광범위하게 이루어질 수 있는 환경을 형성한다. 이러한 현실에서는 독일 형법상 명예훼손 등 범죄에 대한 사후적 처벌만으로는 피해 확산을 방지하기 어렵고, 형벌권 행사가 실질적 기본권 보호로 충분히 연결되지 않는 한계가 드러난다.¹⁷⁾

이와 같은 구조적 한계는 국가의 보호의무를 형사정책 차원에서 재구성하도록 요구한다. 즉, 공익적 목표는 단순히 불법 콘텐츠를 제거하는 데 있지 않고, 표현의 자유와 인격권 보호라는 상충하는 기본권 가치를 제도적으로 조화시키는 데 있다. 디지털 서비스법은 플랫폼에 신고·심사·이유 고지·불복절차 및 투명성 보고 의무를 부과함으로써, 형벌 중심의 대응을 보완하는 협력적 집행 구조를 형성한다. 이는 형벌의 보충성 원칙에 부합하는 방식으로, 형사책임을 전면화하기보다는 구조적 위험을 예방적으로 관리하려는 접근이라 평가할 수 있다. 동시에 표현의 자유는 민주적 의사형성의 전제라는 점에서, 플랫폼 규제는 헌법적 가치질서의 균형 문제로 이해되어야 한다. 디지털 서비스법의 공익적 목표는 불법 행위 억제와 이용자 권리 보호를 동시에 달성하는 데 있으며, 이를 위해 절차적 통제와 비례성 원칙을 제도적으로 구현한다. 디지털 서비스법 제정은 형사법적 사후 책임 모델의 한계를 인식하고, 플랫폼을 기본권 보호를 위한

16) Reda S., Accountability and Transparency in Platform Regulation: Lessons from NetzDG and DSA, *Journal of Media Law*, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 101-127.

17) 정상민, 앞의 논문, 143-146면.

협력적 행위자로 편입시키려는 규범적 전환의 산물이다. 이는 표현의 자유를 위축시키지 않으면서 형사법적 보호법익을 실효적으로 보장하려는 현대적 규제 모델의 형성으로 이해할 수 있다.¹⁸⁾

나. 표현의 자유와 타 기본권 조화를 위한 절차적 통제 구조

디지털 서비스법은 형사법적 사후 책임 구조의 한계를 보완하고, 플랫폼을 협력적 집행 구조 안으로 편입시키려는 공익적 목표에서 출발한다. 그러나 불법 콘텐츠에 대한 신속한 대응이라는 목적은 표현의 자유에 대한 과도한 제한으로 전환될 위험을 내포한다. 따라서 디지털 서비스법의 규범적 핵심은 형사법적 보호법익의 실효적 보장과 표현의 자유 보호를 절차적으로 조정하는 데 있다. 디지털 서비스법은 플랫폼에 불법 콘텐츠의 신고·심사·삭제 의무를 부과하면서도, 그 권한 행사가 적법절차에 준하는 통제를 받도록 설계한다. 플랫폼이 게시물 삭제나 계정 제한과 같은 조치를 취하는 경우, 적용된 법적 또는 약관상 근거와 구체적 사유를 명확히 통지하여야 하며, 이용자에게 내부 불복절차 및 독립적 분쟁해결 절차를 통한 구제 수단을 보장하도록 규정한다. 이는 플랫폼이 사실상 준규제기관적 기능을 수행하는 현실을 전제로, 사적 권한 행사가 자의적 제재로 변질되는 것을 방지하기 위한 제도적 장치이다.¹⁹⁾

형사법적 관점에서 이러한 구조는 책임주의와 명확성 원칙의 절차적 확장으로 이해될 수 있다. 전통적으로 독일 형법은 명예훼손 등 범죄에 대하여 행위자의 책임을 전제로 사후적 제재를 부과한다. 그러나 디지털 환경에서는 플랫폼의 삭제·차단 조치가 사실상 제재적 기능을 수행할 수 있으므로, 그 결정 과정 역시 예측 가능성과 통제 가능성을 갖추어야 한다. 이유 제시, 이의제기, 독립적 검토 절차는 이러한 요구를 제도적으로 구현하는 방식이라 할 수 있다. 이러한 절차적 통제는 기본권 제한의 비례성 원칙을 구조적으로 실현하는 기능을 가진다. 플랫폼이 모든 의심스러운 표현을 일괄적으로 제거하는 대신, 신고 내용과 맥락을 심사하고, 필요 최소한의 범위에서 조치를 취하도록 유도함으로써 과잉 삭제의 위험을 완화한다. 이는 형벌의 보충성 원칙과도 조응

18) 장민영, “디지털 정보접근권 실현을 위한 법적 과제”, 공법학연구 제2권 제4호(2021), 29-32면.

19) 임효준, “인터넷 서비스 제공자를 통한 표현규제에 관한 절차적 보호장치의 탐색: 최근 유럽의 사례를 중심으로”, 언론과 법 22(1) (2023), 251-296면.

하여, 국가가 형벌권을 전면화하기보다 절차적 통제를 통해 기본권 충돌을 조정하려는 접근으로 평가된다.²⁰⁾

다. 투명성과 공적 감독을 통한 플랫폼 책임성 구조화

디지털 환경에서 대규모 플랫폼은 정보 유통과 공론장 접근 구조를 좌우하며, 개별 게시물의 삭제 여부를 넘어 구조적 차원의 권력 행사와 책임성을 요구한다. 형사법적 관점에서, 플랫폼 권한 행사는 단순한 사후적 책임과 달리 사적 주체에 의한 사실상의 제재 기능을 수행하므로, 그 운영 과정과 결과가 외부적·공적 통제 하에 놓여야 한다. 이에 디지털 서비스법은 투명성 확보와 다층적 감독체계를 통해 플랫폼 책임성을 구조화한다. 대형 플랫폼(VLOPs)은 삭제·제한 조치의 유형과 건수, 신고 처리 결과, 자동화 시스템 운용 방식, 위험 평가 및 완화 조치 등을 정기적으로 공개해야 하며, 유럽 연합 집행위원회와 회원국 디지털서비스조정기관, 유럽디지털서비스위원회는 협력적 감독 체계를 통해 규제 준수 여부와 비례성, 내부 통제의 실효성을 점검한다. 이러한 외부적 통제는 형사법적 원칙과 대응된다. 전통적 형사책임에서는 위법행위가 발생한 후 처벌이 이루어지지만, 디지털 플랫폼 규제에서는 권한 행사 자체가 사실상 형사적 보호법익에 직접 영향을 미치므로, 권한 행사 과정 전반을 사전·사후적으로 검증하는 구조가 필요하다. ADR·ODR 기반의 분쟁 해결 체계와 내부 불복절차는 플랫폼 권한 행사에 대한 사후적 검증 기능을 강화하며, 기본권 침해를 신속히 조정할 수 있는 안전 장치를 제공한다. 투명성과 공적 감독을 결합한 다층적 책임 구조는, 형사법적 보호법익을 실효적으로 구현하면서도 표현의 자유와 타 기본권 사이의 균형을 제도적으로 조정하는 장치이다. 이는 플랫폼 규제를 단순한 기술적 삭제 의무가 아니라, 기본권 보호와 공익 실현을 동시에 달성하는 헌법적·형사법적 규범 모델로 구조화한 것으로 이해할 수 있다.²¹⁾

20) York J., Ó Fathaigh R., Protecting Free Expression Under the DSA, *Journal of Digital Rights & Policy*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 45–68.

21) Carmi E.-K., Comandé G., The Digital Services Act: A New Paradigm for Platform Accountability, *Common Market Law Review*, vol. 60, 2023, pp. 1–38.

2. 플랫폼 규제 권한의 헌법적 성격과 표현의 자유 제한 정당화 구조

가. 준규제기관적 플랫폼 권한과 공적 책임의 형사법적 구조

디지털 환경에서는 플랫폼의 삭제·차단 조치가 사실상 사전적·예방적 제재 기능을 수행한다. 이에 따라 플랫폼 권한은 단순한 사적 결정권이 아니라, 기본권 보호라는 공적 법익을 실현하는 준규제기관적 권한으로 이해되어야 한다. 플랫폼이 게시물 삭제, 계정 제한, 알고리즘 기반 조치 등 콘텐츠 규제를 수행할 때, 그 권한 행사는 표현의 자유에 직접적 영향을 미치므로 형사법적 보호법익과 연계된 헌법적 책임을 요구한다. 이러한 구조에서 형사법적·헌법적 정당성은 권한 행사가 예측 가능하고 통제 가능한 절차 속에서 이루어지는지, 과잉 삭제(overblocking)와 사적 검열의 위험이 최소화되는지 여부에 따라 평가된다. 신고·심사·이유 고지, 내부 불복절차, 투명성 보고 및 외부 감독 체계는 이러한 준규제기관적 권한을 헌법 질서 안에 편입시키는 형사법적 장치로 기능한다. 플랫폼 규제 권한의 헌법적 성격은 형사법적 보호법익과 공익적 목표를 조화시키는 제도적 구조 속에서 정의되며, 표현의 자유 제한의 정당화는 이러한 권한 행사에 대한 절차적·투명성·감독적 통제를 통해 확보된다. 이는 디지털 환경에서 사후적 형사책임과 예방적·구조적 통제가 결합된 새로운 규범 모델로 이해될 수 있다.²²⁾

나. 표현의 자유 제한의 헌법적 정당화 기준과 비례성 심사 구조

디지털 플랫폼 규제는 전통적 형사책임이 지닌 사후적 대응 기능을 보완하여 불법 표현과 명예훼손으로부터 공익적 법익을 실질적으로 보호하는 역할을 수행한다. 그러나 플랫폼이 사실상 사전적 제재 권한을 행사함에 따라, 표현의 자유에 대한 제한은 단순한 사적 판단이 아니라 헌법적·형사법적 심사를 전제로 해야 한다. 유럽연합 기본권 헌장 제11조와 제52조는 표현의 자유를 민주적 질서의 핵심으로 보장하면서, 제한이 법률적 근거에 기반하고 권리의 본질적 내용을 존중하며, 목적의 정당성, 수단의 적합성, 필요성 및 최소 침해성을 충족해야 함을 명시한다. 형사법적 관점에서 이러한 기준은 플랫폼 규제 권한이 공익적 보호법익과 충돌할 때, 그 권한 행사에 대한 적법성·정

22) European Commission., Digital Services Act – Guidance for Very Large Online Platforms and Very Large Online Search Engines, 2023.

당성 검토의 핵심 원리로 작동한다. 디지털 서비스법은 플랫폼에게 신고 접수, 심사 기준 적용, 삭제·제한 조치의 이유 통지, 내부 불복절차 및 독립적 분쟁해결제도 보장 등 절차적·외부적 통제 장치를 부과함으로써, 형사법적 보호법익과 표현의 자유 간 균형을 구조적으로 구현한다. 특히 초대형 온라인 플랫폼(VLOPs)에는 체계적 위험 평가와 완화 의무가 부과되며, 유럽연합 집행위원회 및 감독기관이 이행 여부를 검증함으로써, 제한 조치가 공익적 목적 달성을 위해 필요한 범위 내에서 이루어지는지 외부적으로 점검한다. 형사법적 관점에서 플랫폼 규제 하 표현의 자유 제한은 단순한 권한 행사로 정당화되지 않고, 법적 근거, 절차적 통제, 외부 감독, 비례성 심사를 통해 엄격히 제한된 범위 내에서 허용된다. 이는 디지털 환경에서 사후적 형사 책임과 예방적·구조적 통제를 연계하여, 표현의 자유와 기본권 보호를 조화시키는 헌법적·형사법적 규범 모델로 이해될 수 있다.²³⁾

다. 형사법적 관점에서 본 과잉금지원칙의 제도적 구현

디지털 플랫폼 규제는 전통적 형사책임이 개별 불법행위에 대해 사후적 제재를 부과하는 한계를 보완하여, 공익적 법익과 기본권 보호를 구조적으로 조정하는 기능을 수행한다. 그러나 플랫폼이 사실상 사전적 삭제·제한 권한을 행사함에 따라, 표현의 자유에 대한 제한은 자의적 조치로 전환될 위험을 내포한다. 이러한 맥락에서 과잉금지 원칙은 형사법적 보호 목표와 플랫폼 규제 권한 행사를 조화시키는 핵심 기준으로 작동한다. 절차적 통제는 플랫폼의 개별 조치가 법적 근거와 객관적 기준에 따라 이루어지도록 하는 1차적 안전장치로 기능한다. 플랫폼은 불법 콘텐츠 신고 절차를 접근 가능하게 마련하고, 접수된 신고는 관련 법적 기준과 내부 심사 지침에 따라 객관적·일관되게 검토해야 한다. 삭제·차단 또는 계정 제한 조치를 취할 경우, 그 이유와 법적·약관상 근거를 명확히 통지하며, 이용자에게 내부 불복 절차와 독립적 분쟁해결 제도를 통한 대응 기회를 보장해야 한다. 이러한 절차적 설계는 과잉 삭제(overblocking)의 위험을 완화하고, 표현의 자유 제한이 최소침해 원칙에 부합하도록 유도한다. 그러나 내부 절차만으로는 플랫폼의 구조적 권한 행사에 대한 충분한 통제를 달성하기 어렵다. 형사법적 관점에서 이를 보완하기 위해, 디지털 서비스법은 투명성 보고와 공적 감독 체

23) 임효준, 앞의 논문, 264-273면.

계를 외부적 통제로 병행한다. 특히 초대형 온라인 플랫폼(VLOPs)은 콘텐츠 조치 내역, 신고 처리 결과, 위험 평가 및 완화 조치, 알고리즘 운용 주요 요소를 정기적으로 공개하며, 유럽연합 집행위원회와 회원국 디지털서비스조정기관은 이행 여부를 점검하고 위반 시 시정 명령이나 제재를 부과할 수 있다. 절차적 통제는 개별 조치의 정당성을 보장하고, 외부 감독과 투명성 확보는 플랫폼 운영 전반이 표현의 자유의 본질적 내용을 침해하지 않도록 구조적 검증 기능을 수행한다. 이러한 다층적 통제 체계는 형사법적 보호의 연장선에서 과잉금지원칙을 제도적으로 구현하며, 디지털 플랫폼 규제와 표현의 자유 보호 사이의 균형을 실질적으로 조율하는 헌법적·형사법적 안전장치로 평가될 수 있다.²⁴⁾

3. 투명성 보고·이용자 권리 보장 장치를 통한 표현의 자유 보호

가. 형사법적 관점에서의 절차적 통제를 통한 이용자 권리 보호

온라인 플랫폼의 불법 콘텐츠 규제 과정에서, 표현의 자유 침해와 과잉 삭제(overblocking) 위험은 형사법적 관점에서도 중요한 문제로 작용한다. 형사법은 전통적으로 사후적 책임에 의존하지만, 디지털 환경에서는 피해 확산 속도가 빠르고 대규모이므로 단순 사후적 대응만으로는 실효성을 확보하기 어렵다. 이에 플랫폼에 절차적 통제(procedural control)를 부여하는 것은 형사법적 보완 장치로 이해될 수 있다. 플랫폼은 불법 콘텐츠 신고를 접수하면, 명백히 불법인 경우 24시간 내, 판단이 복잡한 경우 7일 내에 삭제·차단 여부를 결정하도록 규정된다. 또한 조치 사유를 게시자와 신고자에게 통지함으로써, 이용자가 이의 제기나 대응을 할 수 있는 권리를 보장한다. 이러한 절차적 장치는 형사법적 관점에서 플랫폼의 준규제기관적 권한 행사가 자의적 사적 검열로 변질되는 것을 방지하고, 기본권 침해를 최소화하며, 공적 보호의무를 보조하는 구조적 수단으로 기능한다. 유럽연합 디지털서비스법(DSA) 역시 VLOPs에 대해 신고·심사 절차와 이용자 대응권(user redress)을 명문화하고, 내부 위험 평가와 심사 기준에 따라 불법·유해 콘텐츠를 조치하도록 한다. 조치 결정에 대한 이유 고지와

24) York J., Ó Fathaigh R., Protecting Free Expression Under the DSA, Journal of Digital Rights & Policy, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 45-68.

이의 제기 보장은, 형사법적 관점에서 피해자의 권리 보호와 플랫폼 책임성 확보를 동시에 실현하는 제도적 장치로 평가된다. 절차적 통제는 형사법적 사후 책임과 예방적·구조적 규율을 연결하여, 표현의 자유 보호와 공익적 목표 달성을 조화시키는 핵심적 법적·제도적 메커니즘으로 기능한다.²⁵⁾

나. 투명성 보고를 통한 플랫폼 책임성과 공익적 권리 보호

플랫폼이 불법 콘텐츠를 규제하는 과정에서 발생할 수 있는 표현의 자유 침해와 과잉 삭제 문제는, 형사법적 책임 구조와 직결된다. 형사법은 전통적으로 피해 발생 후 가해자에 대한 처벌과 배상을 통해 권리를 보호하지만, 디지털 환경에서는 피해 확산 속도가 빠르고 다수에게 영향을 미치므로 사후적 대응만으로는 한계가 있다. 이 점에서 투명성 보고는 형사법적 관점에서 예방적·구조적 책임(accountability) 장치로 기능한다. 플랫폼은 콘텐츠 삭제·차단 조치의 근거, 신고 처리 결과, 내부 심사 기준과 알고리즘 운용 방식을 정기적으로 공개함으로써, 이용자와 사회 전체가 조치 과정을 검증할 수 있도록 한다. 이러한 정보 공개는 단순한 행정적 보고를 넘어, 플랫폼의 준규제 기관적 권한 행사 과정에서 자의적 판단이나 과잉 삭제가 발생하지 않도록 외부적 통제를 가능하게 한다. 또한 이용자는 자신의 권리 침해 여부를 확인하고, 내부 불복절차 및 독립적 분쟁해결 절차를 통해 대응할 수 있어, 형사법적 피해 구제와 구조적 예방이 결합된다.²⁶⁾

결과적으로 투명성 보고는 형사법적 책임의 사전적·예방적 구현 장치이자, 플랫폼 권한 행사의 정당성을 검증하는 도구로 작동한다. 이는 표현의 자유 보호와 공익적 목표 달성을 동시에 달성하기 위한 법적·제도적 기반을 제공하며, 플랫폼 규제의 헌법적 정당성을 강화하는 핵심 요소로 평가될 수 있다.²⁷⁾

25) Jaeger P., Bertot J., Thompson K., Katz S., DeCoster E., The intersection of public policy and public access, *Public Library Quarterly*, vol. 31, no. 1, 2012, pp. 3-8.

26) 임효준, 앞의 논문, 261-263면.

27) Roßnagel Alexander., Friedewald Michael., *Die Zukunft von Privatheit und Selbstbestimmung*, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022, pp. 14-25.

다. 외부 감독과 검증 메커니즘을 통한 사적 검열 위험의 구조적 통제

플랫폼이 불법 콘텐츠를 규제하는 과정에서 행사하는 삭제·차단 권한은, 형사법적 보호법익을 보완하는 예방적 기능을 수행하는 동시에 표현의 자유에 대한 실질적 제한 효과를 발생시킨다. 이러한 권한이 내부 판단에만 의존할 경우, 과잉 삭제나 사적 검열로 전환될 위험이 존재한다. 형사법이 본래 엄격한 책임주의와 법률주의를 통해 국가형벌권을 통제해 온 것과 마찬가지로, 플랫폼의 준규제기관적 권한 역시 외부적 통제를 통해 그 정당성이 담보되어야 한다. 이와 같은 문제의식 아래, 유럽연합의 디지털서비스법은 초대형 온라인 플랫폼(VLOPs)에 대해 공적 감독기관의 지속적 검증을 제도화하였다. 감독기관은 플랫폼이 신고·심사 절차, 내부 위험 평가, 삭제·차단 조치 등 법적 의무를 적법하고 비례적으로 이행하는지를 점검하고, 위반이 확인될 경우 시정 명령이나 제재를 부과할 수 있다. 이는 플랫폼의 권한 행사가 형사법적 보호 목적을 넘어 과도하게 확장되지 않도록 견제하는 외부적 통제 장치로 기능한다. 또한 투명성 보고 자료를 기반으로 외부 이해관계자와 시민사회가 플랫폼 운영을 평가할 수 있도록 한 구조는, 형사법적 책임의 사후적 심사와 유사한 공개적 검증 기능을 수행한다. 다층적 감독 체계는 내부 절차적 통제와 결합되어, 플랫폼의 자율적 판단이 기본권적 한계를 일탈하지 않도록 구조적으로 억제한다. 외부 감독과 검증 메커니즘은 형사법적 책임 원리와 비례성 통제의 연장선상에서, 플랫폼 권한 행사가 표현의 자유의 본질적 내용을 침해하지 않도록 하는 최종적 안전장치로 작동한다. 이는 플랫폼의 준규제기관적 역할을 형사법적 질서 안에 편입시키고, 사적 검열 위험을 최소화하면서 공익적 목표를 실현하려는 제도적 설계로 평가될 수 있다.²⁸⁾

라. 우리나라에의 시사점

우리나라의 경우 사이버 명예훼손 및 온라인 불법정보 규제는 형법과 정보통신망법을 중심으로 한 사후적 형사처벌과 임시조치 제도에 크게 의존해 왔다. 그러나 이러한 규율 구조는 디지털 환경에서 나타나는 피해의 신속한 확산과 반복성, 그리고 플랫폼 구조를 매개로 한 집단적 침해 양상을 충분히 반영하지 못한다는 점에서 한계를 드러

28) 이권일, 앞의 논문, 16-23면.

낸다. 특히 임시조치 제도는 신속한 권리구제라는 장점에도 불구하고, 불명확한 판단 기준과 플랫폼의 자율적 결정에 의존함으로써 과잉 삭제나 표현 위축을 초래할 가능성이 있으며, 반대로 혐오표현이나 반복적 명예훼손과 같은 구조적 침해에 대해서는 실효적 대응이 미흡하다는 이중적 문제를 내포하고 있다. 이러한 국내법적 문제제기가 충분히 정식화되지 않은 상태에서 해외 입법례를 단순히 참조하는 방식은 구체적 제도 설계로 이어지기 어렵다는 점에서 한계가 있다.

따라서 유럽연합 디지털서비스법(DSA)의 논의는 단순한 모델의 수용이 아니라, 우리 법체계의 구조적 문제를 보완하는 방향에서 선별적으로 재구성될 필요가 있다. 형사법적 관점에서 특히 주목해야 할 지점은 다음과 같다.

첫째, 플랫폼의 삭제·차단 조치에 관한 법적 근거와 판단 기준을 보다 명확히 규정할 필요가 있다. 현행 제도와 같이 포괄적·추상적 기준에 의존할 경우, 플랫폼의 자의적 판단이나 과잉 대응이 발생할 수 있으므로, 불법성 판단의 유형화와 단계적 심사 기준을 법률 수준에서 구체화해야 한다. 이는 형사법의 명확성 원칙과 책임주의를 플랫폼 규율에 대응시키는 핵심 장치가 된다. 둘째, 신고·심사·이유 고지·불복 절차를 단순한 자율규범이 아니라 법적 의무로 정립함으로써, 플랫폼 내부 결정 과정에 대한 절차적 통제를 강화할 필요가 있다. 특히 결정 이유의 명시와 기록 보존, 이용자의 이의제기권 보장은 표현 제한이 비가시적으로 이루어지는 것을 방지하고, 사적 검열의 위험을 실질적으로 완화하는 기능을 한다. 셋째, 일정 규모 이상의 플랫폼에 대해서는 투명성 보고 및 외부 감독 체계를 도입하여, 권한 행사의 비례성과 최소침해성을 지속적으로 검증할 수 있는 구조를 마련해야 한다. 이는 단순한 사후 분쟁 해결을 넘어, 반복적·구조적 침해 위험을 관리하는 제도적 기반으로 기능할 수 있다. 넷째, 형사절차와 플랫폼 내부 절차 간의 역할 분담을 명확히 할 필요가 있다. 중대한 명예훼손이나 조직적·악의적 불법정보 유통과 같이 형사법적 개입이 요구되는 영역에서는 공적 형벌권이 중심적 역할을 수행하도록 하고, 경미한 분쟁이나 신속한 권리구제가 필요한 영역에서는 플랫폼 절차를 통한 조정·회복적 해결이 가능하도록 다층적 대응 체계를 구축해야 한다. 다섯째, 디지털 환경에서 구조적으로 취약한 소수자와 사회적 약자가 주요 피해자가 된다는 점을 고려하여, 반복적 혐오표현 및 집단적 명예훼손에 대한 구조적 대응 장치를 마련할 필요가 있다. 이는 단순한 게시물 단위의 삭제를 넘어, 침해의 패턴을 식별하고 완화하는 위험 관리 접근과 결합될 때 실효성을 가질 수 있다. 우리나라에의 시

사점은 단순히 “통합적 구조의 필요성”이라는 추상적 선언에 그치는 것이 아니라, 현행 사후처벌 중심 체계의 한계를 보완하기 위하여 절차적 통제, 구조적 위험 관리, 형사절차와 플랫폼 규율의 기능적 분담을 구체적으로 제도화하는 데 있다. 이러한 접근을 통해서만 표현의 자유 보장과 형사법적 보호법의 실현이라는 두 가지 목표를 디지털 환경에 부합하는 방식으로 조화시킬 수 있을 것이다.²⁹⁾

IV. 결론

디지털 환경에서의 플랫폼 규제는 더 이상 사적 자율규제의 문제에 그치지 않고, 표현의 자유와 형사법적 보호법익이 구조적으로 충돌·조정되는 헌법적·형사법적 영역으로 자리잡고 있다. 우리나라의 경우에도 온라인상 명예훼손, 허위정보, 혐오표현의 확산이 심각한 사회문제로 대두되고 있음에도, 이에 대한 규율은 여전히 형법과 정보통신방법을 중심으로 한 사후적 형사처벌과 임시조치 제도에 크게 의존하고 있다. 그러나 이러한 규율 방식은 정보 확산의 속도와 반복성, 플랫폼 구조를 통한 대량 유통이라는 디지털 환경의 특성을 충분히 반영하지 못하여, 피해자 보호의 실효성과 표현의 자유 보장 사이에서 이중의 한계를 드러내고 있다. 특히 현행 임시조치 중심의 대응은 신속한 권리구제라는 기능에도 불구하고, 불명확한 판단 기준과 플랫폼의 자율적 결정 구조로 인해 과잉 삭제와 표현 위축을 초래할 가능성을 내포하는 한편, 혐오표현이나 반복적 사이버 명예훼손과 같은 구조적 침해에 대해서는 충분한 예방적 효과를 발휘하지 못하고 있다. 이러한 국내법적 문제 상황에 대한 충분한 분석 없이 해외 입법례를 도입하는 접근은 제도 설계의 구체성과 실효성을 담보하기 어렵다. 이러한 한계를 보완하기 위한 참고 모델로서 유럽연합 디지털서비스법(DSA)은 의미 있는 시사점을 제공한다. 다만 그 핵심은 단순한 제도의 수용이 아니라, 형사법의 기본 원리를 플랫폼 규율에 어떻게 접목할 것인가에 있다. 즉, 신고·심사 절차, 삭제 사유 고지, 불복 절차, 투명성 보고, 외부 감독 등은 책임주의·명확성·비례성이라는 형사법의 원칙을 절차적·

29) 최경미, “온라인플랫폼 규제 철학 및 방법 비교 연구: EU 디지털서비스법 · EU 시청각미디어서비스 지침을 중심으로”, 헌법학연구 제30권 제4호(2024), 259-299면.

구조적 장치로 전환한 것으로 이해할 수 있다. 이를 통해 플랫폼은 단순한 중개자를 넘어 공론장 형성에 영향을 미치는 준규제적 행위자로서, 형사법적 보호법의 체계와 연결된 책임을 부분적으로 분담하게 된다. 우리나라에 있어 보다 중요한 과제는 이러한 규범 구조를 국내 현실에 맞게 구체화하는 데 있다. 첫째, 플랫폼의 삭제·차단 조치에 관한 법적 근거와 판단 기준을 명확히 하여, 자의적 판단과 과잉 규제를 방지해야 한다. 둘째, 신고·심사·이유 고지·불복 절차를 법률 수준에서 정교화하여 절차적 통제를 실질화할 필요가 있다. 셋째, 일정 규모 이상의 플랫폼에 대해 투명성 보고 및 외부 감독 체계를 도입함으로써 권한 행사에 대한 구조적 검증을 가능하게 해야 한다. 넷째, 형사절차와 플랫폼 내부 절차 간의 기능적 분담을 통해 중대한 불법행위에 대해서는 형벌권이 중심이 되고, 경미한 분쟁은 신속한 회복적 해결이 가능하도록 다층적 대응 체계를 구축해야 한다. 다섯째, 소수자와 사회적 약자가 주요 피해자가 되는 현실을 고려하여, 반복적·구조적 침해에 대한 위험 관리 체계를 제도적으로 반영할 필요가 있다. 디지털 시대의 형사법적 과제는 사후적 처벌 중심의 전통적 규율을 유지하면서도, 이를 보완하는 절차적 통제와 구조적 위험 관리 메커니즘을 결합하는 데 있다. 이러한 결합은 표현의 자유를 과도하게 제한하지 않으면서도 실효적인 법익 보호를 달성하기 위한 현실적 대안이며, 형벌권의 한계를 준수하면서도 그 보호 기능을 확장하는 방향으로 이해될 수 있다. 나아가 형사법 학계에서 축적되어 온 위법성 조각사유의 정교화, 구성요건 명확화, 피해자 보호 절차 개선 등의 논의를 적극적으로 반영할 때, 비로소 선언적 수준을 넘어선 구체적이고 정책지향적인 제도 설계가 가능해질 것이다. 따라서 디지털 플랫폼 규제의 방향은 추상적 통합 모델의 제시에 그칠 것이 아니라, 국내법의 구조적 한계를 출발점으로 하여 절차적 정당성, 책임 구조, 위험 관리 체계를 구체적으로 제도화하는 데에 두어야 한다. 이러한 접근을 통해서만 표현의 자유 보장과 형사법적 보호법의 실현이라는 두 가치가 긴장 속에서 조화될 수 있으며, 디지털 환경에 부합하는 새로운 형사법적·헌법적 질서의 정립이 가능할 것이다.³⁰⁾

30) Wolters R., Zuiderveen Borgesius F., The EU Digital Services Act: what does it mean for online advertising and adtech?, 2025.

참고문헌

[국내문헌]

- 권형돈. (2020). 인터넷에서 표현의 자유와 그 규제법리: 혐오표현·거짓정보에 대한 독일의 대응을 중심으로. 사법발전재단, 통권 제51호.
- 김현수·전성호. (2020). 유럽연합 디지털서비스법안의 주요 내용 및 시사점. 정보통신정책연구원.
- 박신욱. (2018). 온라인서비스제공자의 책임 및 그 확장에 관한 NetzDG 연구. 법학연구, 21(2).
- 신상현. (2017). 위법한 명예훼손 게시물의 삭제 및 차단의무에 관한 소셜네트워크 운영자의 형법적 책임: NetzDG에 대한 비판적 검토. 법학연구, 20(3).
- 이권일. (2024). 독일에서의 규제 논의의 현황과 과제: 독일 네트워크법(NetzDG)과 유럽연합의 디지털서비스법(DSA)을 중심으로. 공법학연구, 25(2).
- 이은상. (2024). 디지털 격차 해소를 위한 인공지능의 활용과 법제 개선 방안: 고령자, 장애인에 위한 방안을 중심으로. 행정법연구, 제75호.
- 임효준. (2023). 인터넷 서비스 제공자를 통한 표현규제에 관한 절차적 보호장치의 탐색: 최근 유럽의 사례를 중심으로. 언론과 법, 22(1).
- 장민영. (2021). 디지털 정보접근권 실현을 위한 법적 과제. 공법학연구, 2(4).
- 장민영. (2020). 미래세대를 위한 법적 과제 IV: 디지털 정보접근권을 중심으로. 한국법제연구원.
- 정상민. (2024). 소비자 분쟁과 온라인 분쟁해결(ODR): 독일에서의 비판적 논의와 그 시사점을 중심으로. 고려법학, 제115호.
- 최경미. (2024). 온라인플랫폼 규제 철학 및 방법 비교 연구: EU 디지털서비스법·EU 시청각미디어서비스지침을 중심으로. 헌법학연구, 30(4).

[외국문헌]

Carmi E.-K., Comandé G., The Digital Services Act: A New Paradigm for Platform

- Accountability, *Common Market Law Review*, vol. 60, 2023.
- González Fuster Gloria., *Cambridge Analytica: A turning point in data protection?*, *European Data Protection Law Review (EDPL)*, vol. 4, no. 2, 2018.
- Heldt Amélie Pia., *Reading between the lines and the numbers: an analysis of the first NetzDG reports*, *Internet Policy Review: Journal on Internet Regulation*, vol. 8, no. 2, 2019.
- Jaeger P., Bertot J., Thompson K., Katz S., DeCoster E., *The intersection of public policy and public access*, *Public Library Quarterly*, vol. 31, no. 1, 2012.
- Jarass Hans D., Kment Martin., Pieroth Bodo., *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Kommentar*, München: C.H. Beck, 2020.
- Roßnagel Alexander., Friedewald Michael., *Die Zukunft von Privatheit und Selbstbestimmung*, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022.
- Witt Hendrik., Schuh Mathias., *Tatbestand, Zweck und Zweckentfremdung des Auskunftsrechts nach Art. 15 DSGVO*, *Computer und Recht*, vol. 39, no. 4, 2023.
- York J., Ó Fathaigh R., *Protecting Free Expression Under the DSA*, *Journal of Digital Rights & Policy*, vol. 5, no. 2, 2022.
- 小泉雄介., *EUデータ保護規則案の動向と個人データ越境移転*, *ITUジャーナル*, vol. 45, no. 11, 2015.

A Study on the Exercise of the Right to Punish Cyber Defamation and the Criminal Limits of Freedom of Expression*

Hwang, Junghoon** · Song, Hyeonjeong***

The tension between freedom of expression and the protection of reputation in the digital environment cannot be adequately resolved through the traditional ex post criminal liability model alone. Classical criminal law assumes that unlawful expression is punished after harm occurs. Yet on online platforms, defamatory or harmful content can spread instantly and widely, causing large-scale and often irreversible damage. This reality requires the state to go beyond retrospective punishment and actively fulfill its duty to protect fundamental rights.

The Digital Services Act (DSA) addresses this challenge through a cooperative enforcement model. Instead of directly removing content, it imposes procedural and structural obligations on platforms, such as notice-and-action systems, statements of reasons, internal complaint mechanisms, transparency reporting, and public oversight. Platforms are thereby treated as quasi-regulatory actors that significantly shape the digital public sphere, while public accountability is embedded in their moderation processes.

However, this indirect approach carries risks. Expanding private platforms' authority to assess and remove content may lead to overblocking and private censorship, effectively outsourcing state power and indirectly restricting freedom of expression. Therefore, such regulation must satisfy strict constitutional scrutiny. The public interest objective of protecting fundamental rights must be legitimate, and the measures

* This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea(NRF-2021S1A5B5A16077340)

** Researcher, The Research Institute of Law, Hoseo University, Ph.D.

*** Department of Law, Graduate School, Hankuk University of Foreign Studies; M.A. Interpretation and Translation

adopted must comply with proportionality and the prohibition of excessiveness.

Ultimately, regulating unlawful online content is not a simple opposition between freedom and control. It requires an institutional balancing of freedom of expression and the right to reputation. Platform obligations may be justified, but their legitimacy depends on safeguards such as procedural fairness, transparency, multilayered oversight, and effective appeal mechanisms. This represents a governance model that complements traditional criminal accountability while remaining subject to continuous constitutional review.

❖ Keywords: Freedom of Expression, Cyber Defamation, Platform Governance, Digital Services Law, Proportionality Principle